

1501844-08.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501844-08.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501844-08.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222521/2021 - 04º D.P. MAUA, 19657224 - 04º D.P. MAUA, 896/21/206 - 04º D.P. MAUA, 896/2021 - 04º D.P. MAUA, 2222521 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ROBSON SILVA DE OLIVEIRA foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 10h40min, em uma viela comunicante da rua Antônio Negrini, altura do número 884, Parque Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado guardava e expunha à venda,

para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11-2) e laudo de constatação (fls. 18-22).

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.179) e apresentou resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a nulidade da instrução por inobservância ao procedimento relativo ao acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão, da delação premiada e do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno (fls.181-7).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 03-5), auto de exibição e apreensão (fls. 11-2), laudo de constatação (18-22), laudo toxicológico definitivo (fls. 202-5), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial (fls.08-9) e em juízo (mídia digital), o réu manifestou-se.

O policial civil Severino, na fase administrativa (fl.07), historiou que: (sic) "estava em diligências, visando coibir o tráfico de drogas, em companhia do policial Douglas. O depoente estava caminhando sozinho, sendo que seu parceiro, o policial Douglas estava em outro ponto da viela próximo à viatura. Que passando pelo local, o qual já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistou o indivíduo, o qual estava em atitude suspeita. O indivíduo saiu da visão do depoente indo até um terreno baldio com vegetação alta e voltou logo a seguir. O depoente realizou a abordagem e questionou o que ele havia escondido no mato, sendo que o mesmo admitiu estar traficando no local, porém disse que estava realizando a venda de entorpecentes há poucos dias, que estava realizando aquela atividade por necessidade financeira e que ganharia nove por cento do total das vendas. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, sendo que o mesmo mostrou para o depoente onde estava escondido no mato um estojo estampado, onde estariam substâncias aparentando serem entorpecentes, sendo que no mesmo também estava uma pequena quantia em dinheiro. O depoente chamou seu parceiro Douglas através do telefone celular, sendo que o mesmo não presenciou a abordagem, nem o encontro da primeira quantidade de entorpecentes. Foi perguntado ao indivíduo se havia mais entorpecentes escondidos, disse que sim, e levou os policiais civis até um outro ponto na vegetação, a cerca de trinta metros de distância, onde disse que pessoas responsáveis pelo abastecimento da 'biqueira' costumavam deixar as drogas. Os policiais civis encontraram escondida na vegetação uma sacola plástica, com mais substâncias aparentando serem entorpecentes. O indivíduo, posteriormente

identificado como sendo o indiciado Robson da Silva Oliveira, foi apresentado nesta distrital juntamente com o material encontrado e a quantia R\$ 86,00 (oitenta e seis reais)".

Em juízo, o policial Severino disse que o local é conhecido por várias prisões em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Na viela, viu o acusado, com uma pochete na mão, ir até a vegetação, guardar referido objeto e retornar. Ao ser perguntado sobre o que teria guardado na vegetação, o acusado disse que eram entorpecentes. O acusado afirmou que vendia entorpecentes há alguns dias. Ligou para o parceiro, que foi até o local e verificaram que dentro da pochete havia drogas e uma quantia em dinheiro. O réu disse que a cerca de trinta metros havia mais entorpecentes, tendo em vista que uma pessoa teria abastecido a biqueira. No local indicado, encontrou as demais drogas. O acusado disse que estava traficando porque precisava de dinheiro (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

No mais, descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que o policial que realizou a abordagem afirmou que no local conhecido pela prática de tráfico de drogas, viu o réu levar uma pochete até a vegetação, deixar a referida pochete e retornar, demonstradas, assim, fundadas razões para a busca pessoal do réu.

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, e a forma em que era transportada, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de substância entorpecente -56 invólucros de cocaína, 20 invólucros de maconha, 21 invólucros de crack, 02 invólucros de skunk, 151 invólucros de cocaína, 134 invólucros de maconha, 140 invólucros de crack e 10 invólucros de skunk- fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton

Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Na segunda fase, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante na posse das substâncias entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de mera conveniência. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que

ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022).

Na última etapa, incabível o pretendido reconhecimento do instituto da "delação premiada", prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a incidência do referido instituto, os requisitos do mencionado artigo devem estar presentes cumulativamente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDA

ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA RECLUSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a configuração da delação premiada (art. 41 da Lei de Drogas), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos. Conforme consignaram as instâncias ordinárias, nenhuma colaboração foi prestada pelo Agravante no sentido de dados acerca do local e da pessoa que lhe forneceu os 21,70 kg de cocaína. 2. A elevação da pena-base foi adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que, de fato, emprestaram especial reprovabilidade à conduta do Acusado, mormente em se considerando a quantidade e qualidade do entorpecente apreendido. Por consequência, mantém-se o regime fechado (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1301255/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013 - grifo nosso).

Na mesma linha, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) - RECURSO DEFENSIVO [...] DELAÇÃO PREMIADA - Inviável a redução da reprimenda pela aplicação da delação premiada, quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 41 da Lei n.º 11.343/06. [...] Anote-se que o art. 41 da nova lei de drogas menciona requisitos cumulativos para a aplicação da especial causa de diminuição e pela leitura do r. artigo, tem-se que é necessário que a colaboração possa ter efetividade para o desmantelamento de quadrilha ou bando criminoso, ou mesmo para a identificação de outro traficante, possibilitando que se possa oferecer denúncia e processamento do coautor. Desta feita, não há subsídios que apontem que a delação feita pelo apelante tenha se tornado objeto de investigação. Destaco que, no momento da abordagem, seu comparsa conseguiu fugir e o apelante em nada colaborou para sua identificação ou captura. (TJSP; Apelação Criminal 1500713-03.2018.8.26.0540; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).

Na hipótese, não houve qualquer colaboração por parte do réu para descoberta de eventual fornecedor ou outros colaboradores do narcotráfico. A mera indicação do local de armazenamento dos entorpecentes não é suficiente para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

Registre-se, ainda, que, sob o contraditório, não houve cooperação para a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime.

Sobre o tema:

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) [...] - DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO À ESPÉCIE, MOSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE QUAISQUER BENESSES - RECURSO DESPROVIDO. [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo. Não se perca de vista que a ré, em juízo, alterou sua versão dos fatos e alegou que atuava apenas como 'olheira' do tráfico, não contribuindo em momento algum com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, ausente, portanto, qualquer colaboração que permitisse desmantelar o grupo criminoso. Assim, nota-se que a ré apenas admitiu ao ser abordada o que foi constatado pela diligente ação policial e, pelo que se depreende dos relatos dos agentes públicos, indicou o barraco onde estava o restante das drogas e dinheiro pretendendo que com isso fosse

'liberada' pelos agentes públicos, não indicando sequer quem seria o proprietário do local (teria mencionado o nome de "Pamela" na fase de inquérito, porém não forneceu qualquer informação que permitisse a identificação de tal pessoa). [...] (TJSP; Apelação Criminal 1517865-93.2019.8.26.0228; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020 - grifo nosso).

SENTENÇA CONDENATÓRIA DO APELANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT), [...] - APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, ACENANDO COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICANDO-SE DO REDUTOR LEGALMENTE PREVISTO NA FRAÇÃO MÁXIMA E A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS, COM IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), [...] INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação do instituto da delação, prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo, uma vez que o réu não colaborou com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Em verdade, CARLOS afirmou que RICARDO seria mero usuário de entorpecentes, a despeito de o corréu ter admitido em sede policial que era responsável por transportar os entorpecentes (fl. 6), não se insurgindo o Ministério Público a respeito. Tampouco indicou quem seria a terceira pessoa que fugiu por ocasião da abordagem policial, não havendo, portanto, nenhuma colaboração que contribuisse para dismantelar o grupo criminoso. Ressaltando-se, ainda, que as drogas foram localizadas na residência após os policiais sentirem forte odor de maconha vindo do local. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0061634-17.2018.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020 - grifo nosso).

Por fim, não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Todavia, diante das circunstâncias do delito -o réu foi preso em flagrante em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, com significativa quantidade e variedade de entorpecentes, sabidamente dominado por facções criminosas, portanto, sem espaço para "iniciantes no narcotráfico" e não comprovou o exercício de atividade idônea-, parece-me claro o acentuado envolvimento do réu no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

"Não há bis in idem quando o Tribunal a quo fixa a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33 § 4º da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, que restou evidenciada pela quantidade e nocividade da droga apreendida (um quilo de maconha). Também não há bis in idem quando a quantidade e a natureza da droga são consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e, logo depois, no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda" (STJ, AgRg no RESp 1690827 MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Ainda sobre o não reconhecimento do tráfico privilegiado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO

DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos

antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, a sanção em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A multa foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR ROBSON SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e dos objetos apreendidos, bem como decreto o perdimento do valor apreendido, em favor do

Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.
Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
P.I.C.
Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)
Mauá, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA